

1502841-37.2020.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Denise Gomes Bezerra Mota

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/04/2022

... podendo ficar configurado o delito de tráfico de drogas ainda que o agente não tenha sido surpreendido praticando atos de comércio, como no presente caso.

E ainda, mesmo que o réu seja usuário de drogas, tal fato não afasta, necessariamente, a prática do delito de tráfico, pois, como é sabido, na maioria das vezes, os usuários se valem do comércio ilícito de substâncias ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

1ª Vara Criminal

Rua Silvio Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11440-550

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502841-37.2020.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502841-37.2020.8.26.0536

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2228037/2020 - 02º D.P. GUARUJA, 13588439 - 02º D.P. GUARUJA, 699/20/233 - 02º D.P. GUARUJA, 2228037 - 02º D.P. GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIO SILVA DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Denise Gomes Bezerra Mota

Vistos.

Fábio Silva dos Santos, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no crime do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 15 de setembro de 2020, por volta das 11:10 horas, na Rua José Bispo dos Santos, nº 102, fundos, Paecará, nesta cidade e comarca de Guarujá, durante a pandemia de Covid-19, em ocasião de calamidade pública, tinha em depósito e guardava, para o consumo de terceiros, drogas consistentes em 39 (trinta e nove) porções de cocaína, com peso de 274 (duzentos e setenta e quatro) gramas, consoante o auto de exibição e apreensão de fls. 10/11, o auto de constatação preliminar de fls. 12 e as fotografias de fls. 21/ 22, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Foram juntados aos autos os laudos de exame químico-toxicológico realizados na droga apreendida (fls. 112/114 e 115/117).

O réu foi notificado (fls. 87) e apresentou defesa prévia (fls. 102/104), que não comportou acolhimento, e a denúncia foi recebida (fls. 118/120).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas duas testemunhas comuns, duas testemunhas de defesa e o réu foi interrogado (fls. 184). A instrução foi declarada encerrada e pelas partes não foram requeridas diligências, nos termos do artigo 402 do Código de Processo Penal (fls. 182).

O representante do Ministério Público, nos memoriais, requereu a procedência da ação nos exatos termos da denúncia, argumentando que a autoria e a materialidade restaram provadas durante a instrução criminal (fls. 220/236).

Nos memoriais, a defesa requereu a improcedência da ação com a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, em caso de entendimento diverso, requereu a desclassificação da conduta do acusado do artigo 33 para a conduta do artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

Ainda, subsidiariamente, sendo outro o entendimento, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento e a aplicação da atenuante da confissão espontânea, a fixação do regime inicial diverso do fechado, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a concessão ao réu do direito de apelar em liberdade (fls. 243/253).

É o relatório.

Decido.

A ação é procedente.

Com efeito, a materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 02/05, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 10/11, pelo auto de constatação preliminar de fls. 12, pelas fotografias de fls. 21/22, pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 112/114, confirmando-se que as drogas apreendidas eram, efetivamente, cocaína, pelo laudo pericial acostado às fls. 115/117, comprobatório da apreensão de lidocaína, cafeína e tetracaína, que são adulterantes e diluentes comumente empregados na preparação de drogas, pelo laudo pericial anexado às fls. 123/145, atinente às embalagens e aos manuscritos contendo a contabilidade do narcotráfico encontrados, bem como pela prova oral coligida nos autos.

A autoria do réu também restou incontroversa pelas provas produzidas durante a instrução criminal.

Interrogado na fase policial, o réu negou a prática delitiva. Alegou ser usuário de cocaína. Na data dos fatos, policiais civis foram à sua casa para cumprimento de mandado de busca e apreensão e, ao perceber que se tratava da Polícia, pediu um instante de espera para franquear a entrada dos policiais, e jogou a cocaína que guardava para uso pessoal no vaso sanitário de sua residência, pelo temor de ser preso (fls. 15).

Em seu interrogatório judicial, o réu voltou a negar a prática delitiva. Afirmou que tão somente faz uso de cocaína, mas não é traficante. Na data dos fatos, quando notou que a Polícia estava na porta de sua casa, pediu um momento de espera aos policiais para franquear a entrada, dirigiu-se ao banheiro e jogou a cocaína que guardava para uso pessoal no vaso sanitário de sua residência, pelo temor de ser preso. Afirmou que desconhece as embalagens de chup-chup apreendidas e o caderno com anotações manuscritas. Não conhece os policiais que o prenderam (fls. 184).

No entanto, as provas produzidas nos autos demonstraram o inequívoco envolvimento do acusado no tráfico de drogas e não foi apresentada situação capaz de excluir o crime ou isentá-lo de pena.

Senão vejamos.

O policial civil Fabian Carpintero Umbelino, no seu depoimento judicial, relatou que na data dos fatos se encontrava em diligência para cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão na residência do acusado, em razão de denúncia anônima recebida pela Polícia. A equipe foi atendida pelo acusado, por uma fresta da porta, e o acusado pediu um momento de espera para franquear a entrada. O depoente, então, através de um vidro basculante da residência, visualizou que o acusado descartou algo dentro do vaso sanitário. Nesse momento, a equipe entrou na

residência do réu, dirigindo-se ao banheiro, quando foi constatada a presença de vários saquinhos transparentes de chup-chup com pó branco dentro do vaso sanitário, que foram recolhidos. Indagado a respeito, o acusado afirmou que se tratava de uma mistura para adicionar à cocaína. No quarto do réu foram encontrados dinheiro (R\$ 22,00 - vinte e dois reais), anotações manuscritas relacionadas ao tráfico, pacotinhos de folha de seda, 1 (um) rolo de papel filme e 60 (sessenta) saquinhos plásticos comumente utilizados para acondicionar cocaína. O acusado confessou a propriedade dos entorpecentes, bem como dos objetos e do valor apreendidos. O depoente não conhecia o acusado (fls. 184).

Rômulo Augusto do Nascimento Barbosa Martins, policial civil, em Juízo, relatou que na data dos fatos se encontrava em diligência com o policial civil Fabian Carpintero Umbelino - para cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão na residência do acusado, em razão de denúncia anônima recebida pela Polícia. O acusado atendeu a equipe, por uma fresta da porta, e pediu um momento de espera para franquear a entrada. A equipe ouviu um barulho de água e decidiu entrar na residência, empurrando a porta que estava apenas encostada. No banheiro foi constatada a presença de vários saquinhos transparentes de chup-chup com pó branco dentro do vaso sanitário, que foram recolhidos. Indagado a respeito, o acusado confirmou a propriedade dos entorpecentes, dos quais não conseguiu se desfazer, porque não houve tempo de acionar a descarga do vaso sanitário. No quarto do réu foram encontrados dinheiro (R\$ 22,00 - vinte e dois reais), anotações manuscritas relacionadas ao tráfico, 60 (sessenta) saquinhos plásticos de chup-chup - comumente utilizados para acondicionar cocaína - e folhas de seda. O acusado confessou a propriedade dos entorpecentes, bem como dos objetos e do valor apreendidos, e alegou que a droga era para consumo próprio. Embora o réu tenha afirmado que era para consumo pessoal, tudo indicava que no local dos fatos a droga era preparada e embalada para a venda. O depoente não conhecia o acusado (fls. 184).

Ressalte-se que os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade, pois não se pode presumir a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de delito, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial. Ademais, não restou comprovada qualquer razão concreta de suspeição.

A propósito, vem decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça que:

"[...] O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova [...]" (STJ, HC 471082 / SP, Rel. Ministro Felix Fischer, j. 23/10/2018, Dje. 30/10/2018).

"[...] Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, [...]". (STJ, HC 496335 / SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, j. 02/04/2019, Dje 08/04/2019).

Ora, diante dos depoimentos dos policiais civis e da prova material apreendida nos autos, sem dúvida, os entorpecentes apreendidos foram encontrados com o réu e eram destinados para o consumo de terceiros, ou seja, para a venda.

Tem-se que diante do contexto em que ocorreram os fatos, do teor dos depoimentos dos policiais, que narraram de forma segura e harmônica a conduta do acusado, diante da quantidade do entorpecente apreendido, da forma de acondicionamento do entorpecente, das embalagens e das anotações manuscritas apreendidas, e de todas as circunstâncias que culminaram com a abordagem e a prisão do réu, restou comprovada a conduta típica narrada na inicial acusatória.

Portanto, diante das provas produzidas, a autoria do delito é indiscutível. É certo que o acusado tinha em depósito e guardava os entorpecentes, e os entorpecentes eram destinados para o consumo de terceiros, ou seja, para a venda, ante a conduta do réu narrada pelos policiais.

E os depoimentos das testemunhas de defesa não foram capazes de afastar a conduta típica praticada pelo réu.

A testemunha Jair Bispo dos Santos, em seu depoimento judicial, relatou que é

vizinho do acusado e o conhece há mais de 30 (trinta) anos. O depoente, ao longo do tempo em que conhece a família do réu, sempre viu Fábio Silva dos Santos estudando, entregando currículo, trabalhando. O acusado é respeitador, convive em harmonia com a vizinhança. Não presenciou os fatos. O depoente nunca viu movimentação estranha na casa do acusado, pois os rapazes que ficam na frente da casa do acusado são pessoas conhecidas da vizinhança (fls. 184).

Em juízo, a testemunha Marcos Antonio Tenório dos Santos, genitor do réu, afirmou que abriu o portão da casa para os policiais civis, porém, não acompanhou o cumprimento da diligência. Momentos depois do ingresso da Polícia na casa de seu filho, o acusado foi trazido para a frente do terreno algemado e os policiais estavam com um balde, afirmando que havia droga no interior do balde. A casa do depoente não foi revistada pelos policiais. Por ocasião da prisão, o acusado estava desempregado. Quando o réu saiu da prisão, da última vez, arrumou serviço em uma firma, mas depois saiu. Afirmou o depoente que seu filho era usuário de maconha e depois também passou a "cheirar" (fls. 184).

Como se vê, as testemunhas de defesa não presenciaram os fatos, de forma que devem prevalecer os depoimentos dos policiais civis.

Logo, diante das provas produzidas, a autoria do delito é indiscutível. É certo que os entorpecentes apreendidos com o réu eram destinados à venda e ao consumo de terceiros, ante a conduta do réu narrada pelos policiais, destacando-se que o artigo 33 da Lei nº 11.343/06 descreve condutas variadas, podendo ficar configurado o delito de tráfico de drogas ainda que o agente não tenha sido surpreendido praticando atos de comércio, como no presente caso.

E ainda, mesmo que o réu seja usuário de drogas, tal fato não afasta, necessariamente, a prática do delito de tráfico, pois, como é sabido, na maioria das vezes, os usuários se valem do comércio ilícito de substâncias entorpecentes para sustentarem o próprio vício, de modo que uma conduta não exclui a outra, restando afastada a desclassificação do artigo 33 para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

A propósito:

"(...) Ademais, a condição de usuário de drogas não exclui a de traficante, sendo, infelizmente, comum a mercancia realizada por usuários com o intuito de financiar seu vício (...)" (TJSP, Apelação nº 0000136-06.2016.8.26.0626, 5ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Damião Cogan, julgado em 10/05/2019).

Neste sentido, ainda:

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP - HC 42.229-3 -Rel. Onei Raphael - RJTJSP 10/498).

Por fim, o crime de tráfico imputado ao réu restou consumado, uma vez evidenciado que os entorpecentes apreendidos com o réu eram destinados à venda e ao consumo de terceiros.

Definida a conduta do réu, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, considerando os critérios do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, considerando a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido (227 gramas e 300 miligramas de cocaína), que apresenta alto poder viciante, considerando os maus antecedentes do réu (fls. 35/45), elevo a pena-base em 1/6, perfazendo o montante de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, considerando a reincidência específica do réu (fls. 36/38) elevo a reprimenda em 1/6, perfazendo em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Deixo de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, pois na fase policial e na fase judicial o réu afirmou que a droga apreendida era de sua propriedade, porém em nenhum momento confessou a prática do delito que lhe é imputado nestes autos, tão somente afirmou que a droga era destinada a seu consumo pessoal (fls. 15 e 184).

Ainda, na segunda fase, deixo de reconhecer a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. No caso dos autos, verifica-se que o estado de calamidade, em vigência desde o dia 20 de março de 2020, após a publicação do

Decreto Legislativo nº 6/2020, em razão da pandemia de Covid-19, em nada contribuiu ou facilitou a execução do delito. Para a configuração da agravante, deve, pois, existir nexo entre a situação vivenciada no período de calamidade pública e o crime cometido, sob pena de se caracterizar responsabilidade penal objetiva. E, no caso dos autos, não restou comprovada a presença de qualquer facilidade para o cometimento do delito decorrente da situação de calamidade. Permanece, na segunda fase, a reprimenda em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, entendo não ser o caso de aplicação do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/2006. Isto porque, para a sua aplicação, além do preenchimento dos requisitos estabelecidos no tipo penal (agente primário e de bons antecedentes), deve ficar demonstrado que o réu não se dedica a atividade criminosa nem integra organização criminosa, ou seja, deve ficar demonstrado que o réu agiu de forma ocasional. Tem-se que a intenção do legislador, ao permitir a redução das sanções penais, foi diferenciar o traficante contumaz, que dispõe de sofisticado aparato organizado, daquele eventual. No caso dos autos, verifica-se que o réu é reincidente específico (fls. 36/38) e as circunstâncias dos fatos demonstram que o réu fazia do tráfico de drogas meio de vida. Destaco que com o réu foi encontrado caderno com anotações do tráfico e drogas, saquinhos plásticos de chup-chup - comumente utilizados para acondicionar cocaína, e substâncias adulterantes e diluentes comumente empregados na preparação de drogas, tudo a demonstrar conduta reiterado à prática do crime de tráfico de drogas. Sendo assim, deixo e aplicar o redutor na terceira fase, perfazendo a reprimenda o montante de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Torno definitiva a pena aplicada.

Fixo o valor do dia multa em seu patamar mínimo, nos termos do artigo 49, parágrafo 1º, do Código Penal, sendo que o valor do dia multa deverá ser objeto de correção monetária, na forma do artigo 49, parágrafo 2º, do Código Penal.

A pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente em regime fechado, por entender ser o regime adequado à conduta do réu, que demonstrou se dedicar a atividade criminosa.

Ressalte-se que, considerando a pena definitiva aplicada, bem como a gravidade do delito, não são cabíveis os benefícios da substituição da pena ou da suspensão condicional da pena, previstos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

Por fim, considerando que o réu é reincidente, não é possível neste momento apreciar se o réu faz jus à progressão de regime prisional, de forma que eventual progressão de regime será apreciada oportunamente pelo juízo da execução. Destaco que as alterações trazidas pela Lei nº 12.736/2012, que acrescentou o parágrafo 2º, ao artigo 387 do Código de Processo Penal, não revogaram os dispositivos da Lei de Execução Penal, que devem ser considerados para a progressão de regime prisional. Logo, para a progressão de regime não basta apenas a consideração do tempo de prisão provisória, devendo ser preenchidos os requisitos legais dispostos na Lei de Execução Penal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move contra Fábio Silva dos Santos para CONDENÁ-LO à pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por violação ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

O acusado não poderá apelar em liberdade. De fato, preso em flagrante assim permaneceu durante toda a instrução e, agora, com a presente condenação, mais razão ainda para permanecer custodiado. Trata-se de crime extremamente grave e se o réu aguardar o direito de recorrer em liberdade poderá não ser encontrado para a aplicação da presente decisão, tornando-a inócua. Ainda, em liberdade, o acusado poderá reiterar a prática de condutas ilícitas.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontrar.

Nos termos da Lei nº 11.343/2006, após o trânsito em julgado oficie-se à autoridade policial com determinação de destruição da porção de droga reservada para eventual contraprova.

Após o trânsito em julgado, decreto o perdimento do dinheiro apreendido (R\$ 22,00 -

vinte e dois reais), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 10/11, tendo em vista que as provas produzidas nos autos demonstraram tratar-se de produto do tráfico ilícito de entorpecente, bem como determino a destruição das 3 (três) cartelas com folhas pequenas de seda, das 4 (quatro) capas de caderno com anotações manuscritas, da folha com anotações manuscritas, do rolo de filme plástico e dos 60 (sessenta) saquinhos plásticos de chup-chup. Oficie-se, oportunamente.

No que tange às custas processuais, diante da nomeação de Defensor Público Estadual, tem-se que foi deferida tacitamente a assistência judiciária gratuita ao réu. E sendo assim, fica suspenso o pagamento das custas, nos termos do disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/1950.

P. I. C.

Guaruja, 07 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA